Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Assessoria Jurídica

À PRESI/CENTRAL,

O presente administrativo trata de dúvidas acerca da incidência de diversos tributos sobre o Contrato PRESI n° 12/2021, bem como de eventual responsabilidade da CENTRAL pelo pagamento de tais tributos.

Após a prolação de dois Pareceres desta ASSJUR sobre o tema – Parecer 10 (46628498) e Parecer 14 (47724338) -, bem como de manifestações da d. PGE acolhendo, em sua essência, o entendimento da ASSJUR (Manifestação 28 (49723678) e Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE 52587910), o feito retornou à CENTRAL, a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis.

Após o retorno dos autos à Companhia, porém, foi suscitada dúvida pela SUPFIC em 13/6/2023, nos seguintes termos (53741110):

> Ciente do despacho 52587910, informamos que a consulta à Receita Federal foi efetuada em 27/03/2023, entretanto, ficando a dúvida se os imposto renda e contribuições devem ser recolhidos no momento ou aguardamos o parecer conclusivo da Receita Federal.
> A dúvida ocorre em virtude do 2º parágrafo do Despacho final do index 52587910 bem como as opiniões divergentes entre o Paracer 14 47724338 e o despacho em questão.
> Portanto, restituímos para que sejam definidas as questões.

Ato contínuo, o feito foi devolvido à DIRAF (53874440), oportunidade em que se solicitou fosse anexado ao administrativo a consulta realizada à Receita Federal, bem como fossem evidenciados os pontos de divergência mencionados pela SUPFIC.

Em atendimento às solicitações formuladas pela DIRAF, foi anexada ao feito cópia da consulta formulada à Receita Federal (53876555), tendo sido, ainda, prestados os seguintes esclarecimentos adicionais pela SUPFIC, no âmbito do Despacho de Encaminhamento de Documento 53882644:

> Complementando 53876654, e atendendo a sua solicitação, segue abaixo os pontos nos quais observamos divergências de opiniões:
>
> **Parecer 10** - 46628498
> "46. Após análise de tais Atas, bem como do próprio Termo de Constituição de Consórcio, pôde-se concluir que, s.m.j., **foi acordado entre as partes que a identificação, quantificação e pagamento de todos os tributos incidentes sobre o Contrato diretamente ao Fisco compete ao Consórcio Contratado (Consultor), cabendo à CENTRAL, se for o caso, meramente o reembolso de tais valores**."
> "47. Pelo exame da cláusula 38.1 combinada com a cláusula 41.2, entende-se que os tributos locais indiretos passíveis de cobrança já estão sendo reembolsados quando do pagamento das parcelas

discriminadas no item 41.2, razão pela qual **não haveria mais tributos a recolher em relação ao pagamento da Nota INVOICE 43267241."**
"48. Sugere-se, ainda, que a CENTRAL diligencie junto ao Consultor contratado, a fim de averiguar se os tributos incidentes sobre o contrato vêm, ou não, sendo pagos ao Fisco, de modo a evitar eventual pagamento em dobro de tributos devidos à Fazenda, em virtude de possíveis equívocos interpretativos acerca das cláusulas contratuais, bem como qualquer responsabilidade pelo não pagamento de tais tributos."

Parecer 14 - 47724338

(i) No que tange ao IRRF, tendo em vista as informações disponíveis nos autos, **entende esta ASSJUR** que, s.m.j., **não pode ser a CENTRAL considerada como responsável pela retenção na fonte e transferência à União de imposto de renda no caso em tela, considerando que os pagamentos, no âmbito do Contrato PRESI n° 12/2021, são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 744 do Decreto n° 9.580/2018;**
(ii) No que se refere à CSLL, pôde-se concluir que, s.m.j., nos termos da legislação aplicável ao tributo, o Consultor contratado domiciliado no exterior não pode ser considerado contribuinte de tal tributo, afastando-se, pois, sua incidência do caso em tela. Não obstante, ainda que houvesse falar em incidência da CSLL, não poderia a CENTRAL ser considerada responsável pela retenção na fonte e transferência da Contribuição à União, considerando que os pagamentos são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 1°, IN SRF 459/04;
(iii) No que concerne a **PIS/PASEP e COFINS** , nos termos da legislação que rege a matéria, ainda que não seja a CENTRAL a entidade que, faticamente, enseja a ocorrência do fato gerador dos tributos em análise – tendo em vista que, conforme informado pela SUPFIC, os pagamentos ao prestador de serviços domiciliado no exterior são realizados diretamente pelo Banco Mundial -, considerando ser a Companhia a contratante e beneficiária dos serviços prestados, parece ser possível concluir que, s.m.j., deve ser a CENTRAL considerada sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento de PIS/PASEP e COFINS à União;
(iv) Quanto ao ISS, em análise da Lista Anexa da LC n° 116/03, esta ASSJUR concluiu que, ao que parece, os serviços prestados pelo Consultor contratado enquadram-se no disposto no item 2.01 ou, possivelmente, no item 7.03. Cumpre destacar, porém, que a análise acerca do enquadramento, ou não, dos serviços prestados pelo Consultor contratado a uma das hipóteses previstas na Lista Anexa da LC n° 116/03 **é eminentemente técnica, não possuindo esta ASSJUR a expertise necessária para proferir parecer definitivo sobre o tema.** Dessa maneira, cumpre aos setores técnicos da CENTRAL efetuar tal exame. Ultrapassada essa questão, e supondo, a título provisório, haver efetivamente a incidência de ISS ao caso em tela, tendo em vista caracterizar-se a CENTRAL como tomadora dos serviços contratados, nos termos da legislação municipal que rege a matéria, deve se considerar a Companhia como sujeito passivo do ISS perante o Município do Rio de Janeiro, na qualidade de responsável tributária;
(v) Por fim, no que concerne à CIDE-*royalties,* parece a esta ASSJUR que, s.m.j., os serviços contratados enquadram-se no conceito legal de "serviços técnicos", a fazer incidir a CIDE-*royalties* ora analisada, nos termos do entendimento da Receita Federal sobre o tema. Ultrapassada essa questão, parece ser possível concluir que pode a CENTRAL ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 2°, §§2° e 6°, da Lei n° 10.168/2000.

87. Sugere-se, outrossim, seja efetuada consulta à Secretaria da Receita Federal acerca de eventual incidência e obrigação de pagamento pela CENTRAL no que concerne aos tributos analisados de competência da União, a fim de confirmar o entendimento do Fisco sobre a matéria e orientar eventual decisão dos gestores da Companhia.

Dúvidas:

46 Parecer 10 - Se foi acordado entre as partes que a identificação, quantificação e pagamento de todos os tributos incidentes sobre o Contrato diretamente ao Fisco compete ao Consórcio Contratado

(Consultor), cabendo à CENTRAL, se for o caso, meramente o reembolso de tais valores. Sendo competência do Consórcio a identificação, quantificação e pagamento de todos os tributos incidentes sobre o Contrato diretamente ao Fisco.
Já no **Parecer 14 (iii), (iv) e (v)** deve ser a CENTRAL considerada sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento de PIS/PASEP e COFINS à União;

46 Parecer 10 - os tributos locais indiretos passíveis de cobrança já estão sendo reembolsados quando do pagamento das parcelas discriminadas no item 41.2, razão pela qual não haveria mais tributos a recolher em relação ao pagamento da Nota INVOICE.
Já no **Parecer 14 -** Ultrapassada essa questão, e supondo, a título provisório, haver efetivamente a incidência de ISS ao caso em tela, tendo em vista caracterizar-se a CENTRAL como tomadora dos serviços contratados, nos termos da legislação municipal que rege a matéria, deve se considerar a Companhia como sujeito passivo do ISS perante o Município do Rio de Janeiro, na qualidade de responsável tributária;

48 Parecer 10 - diligencie junto ao Consultor contratado, a fim de averiguar se os tributos incidentes sobre o contrato vêm, ou não, sendo pagos ao Fisco, de modo a evitar eventual pagamento em dobro de tributos devidos à Fazenda.
Em se tratando de uma empresa da Espanha, em alguma situação, caberia a esta empresa recolher impostos ao Fisco para neste caso evitar eventual pagamento em dobro de tributos devidos à Fazenda?

(i) Parecer 14 - No que tange ao IRRF, tendo em vista as informações disponíveis nos autos, **entende esta ASSJUR** que, s.m.j., **não pode ser a CENTRAL considerada como responsável pela retenção na fonte e transferência à União de imposto de renda no caso em tela (SIC)**

(SIC) dúvida ocorre em virtude do 2º parágrafo do Despacho final do index 52587910 bem como as opiniões divergentes entre o Paracer 14 47724338 e o despacho em questão.

(ressalta-se que o texto trasncrito acima corresponde exatamente ao que consta no original do documento citado, com os sublinhados e os grifos em vermelho, assim como com o texto encerrado abruptamente no penúltimo parágrafo e o iniciado com minúscula do último, que passam a impressão de estar faltando algum trecho no questionamento)

Pouco depois, em 3/7/2023, o processo foi remetido a esta ASSJUR pela Presidência, "*em razão das dúvidas suscitadas pela SUPFIC no índex nº 53882644, que apontou divergências entres os Pareceres* ***10*** *- 46628498 e* ***14 - 47724338***" (55012868).

É o breve relatório.

O feito foi devolvido a esta ASSJUR, em suma, em virtude de supostas divergências entre os Pareceres 10 (46628498) e 14 (47724338), ambos proferidos por esta Assessoria.

As divergências apontadas, contudo, **são meramente aparentes,** inexistindo contradição entre os mencionados pareceres, conforme se passa a explicar.

Na primeira manifestação proferida por esta ASSJUR sobre o tema - Parecer 10 (46628498) -, inicialmente, buscou-se analisar a **responsabilidade contratual** da CENTRAL acerca dos tributos eventualmente incidentes sobre o Contrato n° 012/2021. Naquela oportunidade, chegou-se à conclusão de que, a despeito de ambiguidades na redação do contrato, as informações contidas nos autos indicavam que

caberia ao Consultor contratado o pagamento dos tributos incidentes sobre o contrato, enquanto à CENTRAL competiria o mero reembolso de tais valores.

Confira-se, nesse ponto, os seguintes trechos do Parecer 10:

> 26. Nesse ponto, conforme se nota da análise dos Anexos – que abrangem, inclusive, diversas tratativas realizadas pelas partes do Contrato, por intermédio de Atas de Reuniões -, verifica-se que foi acordado, entre as partes, que o ônus de pagamento dos tributos incidentes sobre o Contrato recairia sobre o Consórcio contratado, cabendo à CENTRAL, portanto, se for o caso, apenas o reembolso de tais tributos.
> [...]
> 28. O trecho acima transcrito denota a obrigação do consórcio de discriminar os tributos previstos sobre o contrato, o que, s.m.j., indica o acordo entre as partes no sentido de atribuir ao Contratado o ônus de discriminar, calcular e pagar ao Fisco os tributos incidentes sobre o Contrato.
> [...]
> 30. De igual modo, o trecho acima transcrito indica a obrigação do Consórcio contratado de pagar os tributos incidentes sobre o Contrato ao Fisco, uma vez que, s.m.j., pouco sentido haveria falar em incorporação dos tributos no custo da remuneração caso tal obrigação houvesse de ser arcada diretamente pela CENTRAL.
> [...]
> 32. Como visto, o trecho acima indica a necessidade de revisão do valor do contrato na hipótese de cobrança de tributos brasileiros, o que, mais uma vez, indica que o ônus de pagamento dos tributos ao Fisco incide sobre o Consórcio contratado. Isso porque, caso tal ônus recaísse diretamente sobre a CENTRAL, não haveria falar em necessidade de revisão do valor previsto no Contrato, uma vez que tal circunstância em nada afetaria o equilíbrio econômico-financeiro para o Contratado.
> [...]
> 35. Desse modo, considerando todo o cenário acima exposto, em resposta à consulta formulada, entende esta ASSJUR, s.m..j, que na fase de negociação os "impostos" indiretos ficaram a cargo do consultor contratado, cabendo a este realizar os pagamentos, de forma que **não há falar em isenção da prestadora de serviços da retenção dos tributos devidos ao Fisco.**
>
> 36. Observando-se todas as tratativas realizadas entre as partes, portanto, que também integram o contrato (24631022) , **deve prevalecer o disposto no item 38.1, referente à "PARTE III - CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO", cumprindo à CENTRAL realizar** – se for o caso – **meramente o reembolso de tais valores.**
>
> 37. Inclusive, depreende-se que o valor informado no item **38.1** do contrato, em moeda estrangeira, se refere ao preço do contrato no montante de **US$ 142.500,** encontrando-se destacado o valor de todos os tributos locais indiretos passíveis de cobrança no montante de **US$ 18.531,50. Somando esses valores, chega-se ao total de US$ 161.031,50.**
>
> 38. Ao analisarmos o valor da Nota INVOICE 43267241, a cujo questionamento se refere a consulta formulada, verifica-se que aquela representa o 1º pagamento do contrato (5,98% do valor global dos serviços, equivalente a **US$ 9.632,67**). Assim, somando-se todos as parcelas em moeda estrangeira do item 41.2 do contrato, chega-se ao montante total de **US$ 161.031,50, que é justamente o valor do preço + tributos locais, de modo que se pode inferir que o valor dos tributos já está sendo reembolsado quando do pagamento das notas fiscais.**
>
> **39. Assim, s.m.j., não há mais tributos a recolher em relação ao pagamento da Nota INVOICE 43267241.**
>
> 40. Sugere-se, pois, que a CENTRAL diligencie junto ao Consultor contratado, a fim de averiguar se os tributos incidentes sobre o contrato vêm, ou não, sendo pagos ao Fisco, de modo a evitar eventual pagamento em dobro de tributos devidos à Fazenda, em virtude de possíveis equívocos interpretativos acerca das cláusulas contratuais, bem como qualquer responsabilidade pelo não pagamento dos

tributos.

Como visto, portanto, no âmbito do Parecer 10, concluiu-se que, na relação firmada entre as partes, teria ficado **acordado** ser o Consórcio contratado o responsável pelo pagamento dos tributos ao Fisco, enquanto à CENTRAL competiria o mero reembolso de tais valores. **Naquela oportunidade, sugeriu-se, inclusive, fosse o Consultor contratado indagado acerca do efetivo cumprimento de tal obrigação contratual, a fim de possibilitar que, se fosse o caso, a Companhia tomasse as providências necessárias ao adequado cumprimento das obrigações contratuais pelo contratado**, inclusive pelo fato de que esta ASSJUR entendeu que o valor dos tributos indiretos já estariam incluídos no valor de reembolso quando do pagamento das parcelas discriminadas no item 41.2. **Ou seja, o Parecer 10 analisou a questão cível, contratual, existente entre as partes**.

O Parecer 14 (47724338), por outro lado, buscou analisar **questão diversa**. Na segunda manifestação proferida por esta ASSJUR sobre a matéria, o cerne da questão passou a ser a **análise de quais tributos em espécie seriam incidentes sobre o Contrato n° 012/2021**, bem como **se seria a CENTRAL responsável tributária pelo pagamento de tais tributos perante o Fisco. O Parecer 14, portanto, faz uma análise trbutária da questão, envolvendo o contribuinte e o responsável pelos pagaementos dos tributos.**

As questões embora relacionada e complementares são diversas.

Tal ponto foi, inclusive, explicitado no âmbito do Parecer 14, conforme se infere do seguinte trecho:

> 13. Após a prolação do Parecer 10 (46628498), esta ASSJUR foi novamente questionada acerca da incidência de tributos sobre o Contrato PRESI N° 12/2021, tendo sido destacado pela DIRAF que " *o setor financeiro apurou (Lei 10.865 de 30/04/2004, dentre outras) também, a existência além dos impostos indiretos que não foram discriminados no referido contrato PRESI 012/2021, a ocorrência também das obrigações a pagar pelo contratante de serviços no exterior, no caso a CENTRAL, das contribuições Federais (PIS, COFINS, CSLL e CIDE*)" (46783277).
>
> 14. Sobre o tema, cumpre destacar, preliminarmente, que **todas as conclusões exaradas por esta ASSJUR no âmbito do Parecer 10 permanecem hígidas, entendendo esta Assessoria que, s.m.j., cumpre ao consórcio contratado o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o Contrato ao Fisco, competindo à CENTRAL meramente o reembolso de tais valores**.
>
> 15. Por outro lado, é certo que, **ainda que plenamente válidas e eficazes perante as partes, as cláusulas contratuais não produzem efeitos perante o Fisco,** nos termos do art. 123, do CTN, *in verbis*:
>
> > Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, **as convenções particulares**, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, **não podem ser opostas à Fazenda Pública** , para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
>
> 16. Isso significa, pois, que, na hipótese de a legislação tributária prever que a responsabilidade pelo pagamento de determinados tributos, no caso concreto, competiria à CENTRAL, tal circunstância constituiria óbice à oposição das cláusulas do Contrato PRESI n° 12/2021 ao Fisco, sem prejuízo, porém, do eventual ajuizamento de ação de regresso em face do consórcio contratado, a quem compete, s.m.j., o pagamento dos tributos incidentes sobre o contrato.
>
> 17. Dessa maneira, o presente Parecer será elaborado considerando a eventual responsabilidade tributária pelo pagamento de tributos incidentes sobre o Contrato PRESI n° 12/2021, por parte da CENTRAL, perante o Fisco, sem prejuízo das ressalvas acima apontadas.

Melhor explicando, o que ocorre em termos práticos é que, por vezes, a legislação tributária determina, *e.g.,* que compete ao indivíduo X o pagamento de determinado tributo. Nada impede, contudo, que, em suas relações contratuais, o indivíduo X acorde com o indivíduo Y que este ficará responsável pelo recolhimento e pagamento do tributo em questão. Caso isso ocorra, tal contrato será plenamente válido e eficaz **apenas entre as partes**.

O que se verifica, porém, no exemplo acima, é que eventual contrato firmado nesses moldes **não será oponível ao Fisco.** Isto é, caso Y não recolha e pague os tributos acordados, o Fisco poderá inscrever em Dívida Ativa e ajuizar execução fiscal em face de X, o qual, este, não poderá opor o acordo celebrado com Y à Fazenda Pública.

A Fazenda Pública, portanto, poderá cobrar e executar X pelo tributo que lhe é devido, **sem prejuízo de uma futura ação de regresso de X em face de Y,** uma vez que, como dito, o contrato por eles firmado é plenamente válido e eficaz **entre as partes, ainda que não seja oponível à Fazenda.**

Tornando um pouco mais concreto o exemplo acima, somente para facilitar a compreensão, pode-se citar um caso usual em que esssa sistemática é adotada e que é de conhecimento geral: transferência em uma relação locatícia da obrigação de pagar o IPTU do Proprietário-Locador para o Locatário. Essa tranferência usualmente feita pelo contrato de locação, embora válida entre as partes (regra de direito civil, contratual, válida entre Proprietário-Locador e Locatário) não é oponível ao Fisco que, no caso de inadimplemento, cobrará o IPTU do Contribuinte, que no caso é o Proprietário-Locador (regra de direito tributário).

Ultrapassado o exemplo acima e retornando ao caso concreto do presente administrativo, como dito, o que se analisou no Parecer 10 foi eventual **responsabilidade da CENTRAL** pelo pagamento de tributos **no âmbito do contrato firmado entre as partes.** Neste ponto, concluiu-se que, s.m.j., **caberia ao contratado, e não à CENTRAL, o pagamento dos tributos incidentes sobre o contrato.**

Por outro lado, no Parecer 14, f**oi efetuada a análise de eventuais tributos devidos pela CENTRAL ao Fisco.** As conclusões do Parecer 14 não invalidam, em nada, as conclusões do Parecer 10, que permanecem íntegras. Desse modo, eventual responsabilidade tributária da CENTRAL perante a Fazenda Pública não eximirá o Consórcio contratado de suas obrigações contratuais, de maneira que, na hipótese de o contratado **não recolher e pagar os tributos devidos**, ainda que a CENTRAL seja considerada responsável tributária perante o Fisco, caberá o ajuizamento de ação de regresso perante o contratado, a fim de obter o ressarcimento pelos valores despendidos pela Companhia.

Foi nesse sentido, portanto, que se considerou que, **perante a Fazenda Pública,** seria a CENTRAL, ao que tudo indica, responsável pelo pagamento dos seguintes tributos: PIS/PASEP e COFINS; ISS (a depender de análise a ser realizada pelos setores técnicos da Companhia sobre este imposto); e CIDE-royalties.

Nada obstante, repita-se que, concretamente, a Companhia só deverá pagar diretamente tais tributos ao Fisco **caso o Consórcio contratado não esteja recolhendo tais tributos, sob pena de seu pagamento ocorrer em duplicidade.**

Por tais motivos, reitera-se a recomendação exarada no âmbito do Parecer 10, **sugerindo-se que a CENTRAL diligencie junto ao Consultor contratado, a fim de averiguar se os tributos incidentes sobre o contrato vêm, ou não, sendo pagos ao Fisco.** Em caso negativo, faz-se possível o recolhimento e pagamento dos tributos supramencionados à Fazenda Pública diretamente pela CENTRAL, **sem prejuízo, porém, da obtenção de ressarcimento de tais valores junto ao Contratado, uma vez que, conforme esposado no Parecer 10 (46628498) , ao que tudo indica, os valores pagos pela Companhia ao Consórcio contratado já incluem o reembolso correspondente aos tributos incidentes sobre o Contrato n° 012/2021.**

Espera-se, pois, que as considerações tecidas acima sejam suficientes para sanar a aparente contradição entre os Pareceres 10 e 14. Nada obstante, na hipótese de surgimento de dúvidas supervenientes sobre o tema, esta ASSJUR se encontra à disposição para prestar outros esclarecimentos.

Aproveita-se a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2023.

MAURÍCIO GOMES VIEIRA
Procurador do Estado do Rio de Janeiro
Assessor-Chefe da ASSJUR/Transportes
Id. 43872158

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Gomes Vieira**, **Procurador do Estado**, em 04/07/2023, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **55160739** e o código CRC **8830AFA7**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001883/2022 SEI nº 55160739

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: